

luego consecuencias en el seno no solo de la familia sino también en el de la sociedad.

c) El *Testamentum Procinctum*

Procedía en tiempos de guerra; era atípico, porque no se exigían las formalidades propias de otros testamentos, podía ser oral o escrito. El testador militar podía ser mudo o sordo, el acto gozaba de plena validez. De éstos privilegios participaban solo aquellos que estuviesen activos en campaña, no correspondía a los militares veteranos o los activos de licencia.

d) El *Testamentum per aes et Libram*

Mediante el ritual del cobre y de la balanza en presencia de cinco ciudadanos romanos y el libripens, obraba como una venta ficticia. Con el tiempo cayeron los dos primeros en desuso permaneciendo vigente el último. Pero de a poco las Constituciones Imperiales y la costumbre establecieron como válido tanto para el derecho civil con para el derecho honorario, la univocidad del testamento, la presencia de siete testigos (derecho civil), firma de los testigos (constituciones Imperiales) y sus sellos (edicto del pretor)

e) El Testamento escrito

Puede ser realizado de mano del testador, denominado ológrafo, o de un tercero como lo sería un esclavo con la autorización del primero. Es válida la realización de un solo testamento en varios ejemplares originales.

VII. La Función de los testigos

En el *Testamentum per aes et libram*, se hacía necesaria la presencia de cinco testigos ciudadanos romanos, púberes, si bien luego por el derecho civil y el honorario se establece la necesidad de la univocidad del acto, los siete testigos con la inclusión de sus sellos (no ofrece discusión las características de los sellos, en cuanto a que sean iguales o distintos), y la suscripción del testador, todo ello para garantizar la legitimidad del acto que era de vital trascendencia para la comunidad. Otra cuestión que se previó era la inclusión del nombre del he-

redero ya sea de puño y letra del testador o de los testigos para evitar situaciones dudosas, duda surgida del dolo: aceptación de la herencia por otro; o del error de llamar a heredar alguien que no corresponde. En cuanto a las incapacidades son las ya conocidas: la exclusión de la mujer, del pródigo, *furiosus*, impúberes, esclavos, mudos, sordos, etc. Con la aclaración que si al momento de suscribir como testigo un testamento posteriormente cae en esclavitud, la participación como testigo es válida, ya que la esclavitud es posterior a dicho acto y no tiene efectos retroactivos. No es impedimento poner como testigos a familiares, siempre y cuando no lo sean del testador.

VIII. *Delatio hereditatis*

La Delación o llamamiento a la herencia se podía realizar por voluntad del causante expresada en un testamento válido (ex testamento) o por imperio de la ley (ab intestato). La *delatiohereditatis* tenía por lugar la muerte del autor de la sucesión, al cumplirse la condición legal necesaria para que los actos mortis causa comenzaran a producir sus efectos. El llamamiento a herencia no podía hacerse por un contrato hereditario mediante el cual el causante designara como heredero o legatario a la otra parte o a un tercero, porque tal convención se considera contraria a las buenas costumbres y consiguientemente nula. La sucesión intestada era excluida por la testamentaria. Se abría aquélla a falta de testamento o cuando no fuera válido o resultara inválido con posterioridad. La sucesión ab intestato no podía darse simultáneamente con la ex testamento por aplicación de la regla que nadie podía morir en parte testado y en parte intestado, lo cual significaba que a un heredero no le era dable recibir su investidura por el testamento al mismo tiempo que por la ley. El causante no disponía en su testamento de toda la herencia o dejaban de ser herederos algunos de los instituidos testamentariamente, el resto de la herencia no la adquirían los herederos *ab intestato*, sino que acrecía a los demás testamentarios, en proporción a sus respectivas cuotas.

IX. Distinción de herederos

En Roma, quien estaba investido de la calidad de heredero no podía dejar de serlo, por aplicación de la regla *semel heres, semper heres*. La institución de heredero es pura o bajo condición, si la condición fuese imposible se tiene por no realizada o escrita, las condiciones pueden ser disyuntivas, es suficiente que se cumpla una u otra. También puede ser *here* una persona que nunca ha sido conocida por el testador.

Había que distinguir entre las siguientes clases de herederos:

a) Los herederos sui

Se les equiparaban los esclavos instituidos por sus amos. Eran herederos necesarios, pues adquirirían tal investidura por el hecho de la muerte del *de cuius*. La Lex Aelia Sentia prohibió que haya más de un heredero necesario esclavo si ello ocurría la institución era nula. En cambio si se designaba a dos por ejemplo, producido el fallecimiento de uno de ellos se mantenía la designación como único heredero la del segundo. Cuando la mujer ha cometido adulterio con un esclavo, después no puede instituirlo su heredero, con más razón si fueron condenados por ese delito.

b) Herederos legítimos o testamentarios

Eran herederos voluntarios, ya que solo se hacían herederos cuando aceptaban la herencia. El testado lo instituía de una manera sencilla: “Sea Cornelio el dueño de mi herencia”; “Sea heredero mi hijo Seyo que siempre faltó a sus deberes filiales”; las dos formas son válidas.

Con respecto a los herederos voluntarios, la herencia recorría tres etapas:

- 1) De la delación de la herencia, tenía lugar a la muerte del causante (*hereditas delata*)
- 2) Cuando los herederos entraban en la herencia y adquirían la calidad de tales (*hereditas adquisita*).
- 3) Etapa intermedia entre las dos primeras, cuando la *hereditas* carecía de dueño o estaba yacente (*hereditas iacens*).
- 4) En el caso de los herederos necesarios, no se presentaba la tercera

etapa, porque al operarse la transmisión de los derechos hereditarios por la sola virtud del fallecimiento del *de cuius*, se confundía la adquisición de la herencia con la delación.

- 5) La *Hereditas* otorgaba a su titular, el *heres*, una acción civil, la petición de herencia (*actio petitio hereditatis*), para hacer valer los derechos que le correspondieran por su llamamiento a la sucesión.
- c) Los herederos extraños o voluntarios

Eran aquellos instituidos herederos por el pater, pero no tenían vínculos familiares con éste. El límite a ésta potestad de testar estaba en no afectar la porción que por ley les correspondía a los herederos legítimos, por ejemplo se podía nombrar heredero a aquél que se lo quiere con cariño fraterno si se lo llama “hermano” y se lo designa con ese nombre.

X. La *adquisitio hereditatis*

Era la adición o aceptación de la herencia para que el heredero la adquiriera.

La *adquisitio hereditatis* constituía, la etapa en la que la herencia era adquirida por el sucesor. Algunos herederos calificados de “necesarios”, lo hacían de pleno derecho (*ipso iure*), es decir sin su consentimiento y hasta contra su voluntad. En esta situación se encontraban los *filiifamilias* sometidos a la potestad del causante a tiempo de su muerte (*heredes sui etnecessarii*) y el esclavo manumitido en el testamento e instituido heredero por su amo (*heredes necessarii*). Para los otros herederos denominados “voluntarios” (*heredes extranei velvoluntarii*), la adquisición de la herencia se producía previa aceptación que se efectuaba por medio de un acto jurídico llamado adición (*aditio*).

XI. Testamento *irritum*

Un testamento es *irritum* cuando ocurre algo en relación al que testa, por ejemplo, sufre una *capitis deminutio* y se transforma en un esclavo; también cuando era condenado a pelear contra las bestias o

como gladiador. En el caso de que escapara de la esclavitud si regresaba a Roma ese testamento era válido, pero en caso de que muera es irrito a partir de la sentencia que lo declara como tal, no a partir de la muerte del testador.

Otro caso de *capitis deminutio* que aparejaba *testamentum irritum* ocurría cuando alguien era deportado a partir de que la misma quedaba consumada.

Se declaraba con ésta condición el testamento de los suicidas que sabían que habían cometido un delito, pero los suicidios cometidos por vejez o enfermedad no acarreaban ésta consecuencia.

Tienen también ésta condición los testamentos de aquellos que después de morir habían sido condenados (su memoria) por delitos de alta traición.

XII. La desheredación

Es hecha por el testador en forma expresa o no, ya sea mencionándolo expresamente, o por otro tipo de indicaciones, pero con clara referencia a persona identificable, caso contrario no puede haber desheredación válida.

Por ejemplo:

- a. “Que mi hijo Varrón sea desheredado”; o
- b. “Que mi hijo Atio sea desheredado”, sin nombrar a nadie si no tiene otro hijo.

a) Los Póstumos

Se establece que los hijos póstumos deben ser instituidos o desheredados de acuerdo con las pautas señaladas precedentemente, lo mismo ocurre respecto de la actitud tomada por el pater cuya bajo potestad se encuentran hijos y nietos, puede desheredar tanto a los unos como a los otros, para no caer en invalidez testamentaria.

b) Los emancipados

Con respecto a los filii emancipados, el derecho civil establece que no hay obstáculo para instituirlos o desheredarlos, pero el pretoriano, establece que quienes no sean instituidos sean expresamente deshe-

redados, los varones nominalmente y las mujeres *interceteros*, si no se daban éstas circunstancias descriptas el pretor concedía la *Bonorum possessio* contra tabulas.

c) Los Adoptados

Mientras subsista el vínculo entre adoptantes y adoptados, su régimen se asimila a los hijos concebidos en las *justiae nuptiae* con respecto a lo ya expresado. Si fueron emancipados no hay obligación de instituir o desheredar porque son extraños a la familia.

En el derecho antiguo se hacía la distinción entre varones y mujeres pero con el tiempo se equipararon con las mismas consecuencias jurídicas.

d) El heredero del militar

Si no hizo desheredación nominal, su silencio con respecto a instituir a un hijo o nieto, se interpreta como una desheredación nominal salvo que no supiera de la existencia de éstos.

La desheredación hecha por el padre tiene los mismos efectos si hubiese silencio de la madre o del abuelo, aunque éstos últimos no tienen obligación de desheredar o instituir.

XIII. El acrecimiento

Si hay un solo heredero le corresponde la totalidad del patrimonio, aún cuando haya sido instituido por una parte de él por aplicación de un principio jurídico que nadie puede morir en parte testado y en parte intestado – *nemo pro parte testatus por parte intestatus decedere potest*–.

Cuando son varios los designados, si es la voluntad del testador que todos reciban por partes iguales no señala la parte que le ha de corresponder a cada uno, por una cuestión lógica. En cambio si a algunos herederos se les ha indicado la parte que les corresponde y a otros no, entonces éstos últimos concurrirán en partes iguales con lo que sobrare de la porción hereditaria que no tuviese asignada heredero, caso contrario los que tienen porción asignada toman la mitad de la herencia y quienes no la tienen la otra mitad.

XIV. Clases de sustituciones

a) La Sustitución Vulgar

Por testamento se pueden designar distintas clases de herederos: “Si Titaso no hereda, que herede Sempronio” y así sucesivamente si quiere el testador, llegando a instituir como heredero necesario a su esclavo, también:

- 1) “Que A, B, C, Y D hereden, sino que lo haga Cornelio”;
- 2) “Que A, B, C, D, E, hereden sino que lo hagan A respecto a B, C respecto a D y E,”
- 3) “Que Varrón me herede sino que lo hagan A, B, C, Y D”.

b) La Sustitución Pupilar

Cuando se trata de impúberes que se encuentran bajo la potestad se los puede sustituir, no solo como herederos de uno, sino, que si mueren impúberes después de haber heredado, otros hereden lo que éstos han dejado:

“Que Cornelius mi hijo sea mi heredero, o si habiéndolo sido, muere antes de haber llegado a su propia tutela (es decir antes de ser púbero), que Estacio sea a heredero.

XV. Sucesión Intestada

a) La sucesión del derecho civil

Se distingue entre herederos sui, y herederos extraños o voluntarios, denominados *extranei heredes*.

b) Sucesión de los herederos sui por la *Ley de las XII tablas*

Cuando un paterfamilias moría sin dejar un testamento lo sucedían necesariamente los hijos quienes se transformaban en sui iuris. Quedaban comprendidos en la categoría de *heredes sui* los hijos e hijas sometidas a la potestad del causante, la *uxor cum manu*, también entraba dentro de ésta categoría, ya que ocupaba el lugar de hija.

c) Sucesión de los *extranei heredes*

Si el que moría intestado no dejaba herederos sui, lo cual ocurría forzosamente con las mujeres que no ejercían potestad sobre persona alguna, las XII tablas atribuían la herencia al agnado más próximo.

Agnados eran parientes que pertenecían a la misma familia, los que habrían estado bajo la misma potestad del difunto de no haber desaparecido el antecesor común.

En éste llamamiento legal no se hacía distinción de sexos. Por una *Lex Voconia* del 169 a.C. que impidió a las mujeres ser instituidas herederas por los ciudadanos de la primera clase del censo, dio lugar a la jurisprudencia para extender aquella restricción a la sucesión intestada, e incluso para excluir de la sucesión legítima a las mujeres más allá del segundo grado, admitiendo tan solo a las hijas y a las hermanas.

División de la herencia: Entre los herederos domésticos, la herencia se dividía por cabeza (*per capita*). En partes iguales, cada una de las cuales, se llamaba cuota viril. Pero si había premuerto uno de los hijos dejando descendientes bajo la potestad del abuelo, la división se hacía por stirpes (*in stirpes*) y los descendientes heredaban la cuota viril que hubiera heredado su padre de no haber premuerto (derecho de representación).

XVI. La *hereditas* y la *bonorum possessio*

El derecho romano conoció dos especies de sucesión universal *mortis causa*, la *hereditas* y la *bonorum possessio*, que se diferenciaban sustancialmente por el origen, pues la *hereditas* provenía del Derecho Civil y la *Bonorum Possessio* deriva del derecho Pretoriano u Honorario.

La *hereditas* y la *bonorum possessio* tuvieron en común que ambas instituciones implicaban sucesión universal por *mortis causa*, pero sus diferencias eran notorias en diversos aspectos, no sólo en lo relativo al origen, civilista una, pretoria la otra, sino también a sus efectos, modos de adquisición, formas de protección, etc.

A) La *Hereditas*

Era el conjunto de derechos y obligaciones que integraban el patrimonio del causante, además de la materialidad que componía el acervo traducido en bienes tangibles.

Llamado a recibir la *hereditas* era el *heres*, el heredero según el derecho civil, cuya investidura provino de las XII Tablas y más adelante de los *senadoconsultos* y de las constituciones imperiales. Se trataba de un sucesor de toda la herencia, un sucesor a título universal (*in universum ius*), no particular. Era continuador de la personalidad jurídica del de *cuius*, o causante.

B) La *Bonorum Possessio*

a) Definición

Es el derecho de perseguir o de retener el patrimonio del difunto.

b) Orígenes

Hay distintas controversias en los que se refiere a sus orígenes, se presume que se relaciona con el poder que el pretor tenía de adjudicar la cosa litigiosa a alguna de las partes en el proceso, hasta que se resolviera la cuestión definitivamente y quedara en poder de una de ellas.

La *Bonorum Possessio* no surge como sistema contrapuesto al sistema civil. Su fin es el de ampliar la base de las vocaciones hereditarias, de acuerdo con la nueva significación asumida por los testamentos y con las ideas acerca del parentesco cognaticio. Si es cierto que la *Bonorum Possessio* originaria se moldeó según principios estructurales de la *Hereditas*, no es menos verdad que dándose un fenómeno de constante interferencia entre las normas de uno y otro sistema, se llegó a una fusión de gran alcance conceptual: la herencia pretoria se configura como *successio in ius defuncti*, es decir, de conformidad con los principios del *Ius Civile*.

De una parte, se amplía el orden sucesorio civil (intestado), mediante una ficción que equipara los *emancipati* a los *sui*; de otra parte, se coordina el sistema pretorio con el sistema civil, para quedar un

sistema único de sucesión, dividido en cuatro clases: *liberi*, *legitimi*, *cognati*, *vir et uxor*. Una consecuencia natural de la nueva ordenación es la de admitirse las delaciones sucesivas, incluso entre los varios grados del rango legitimario.

En la herencia pretoria las vocaciones hereditarias no responden a la posición que los llamados ocupan en la familia, sino a la razón del parentesco. Y siendo cierto que tales vocaciones se cifran en derechos subjetivos de carácter patrimonial, cabe su renuncia. Mientras la *hereditas* se impone obligatoriamente a los *sui heredes*, cuando no son extraños o voluntarios, la *Bonorum Possessio* es concedida en tanto se solicita del magistrado, y si para la primera rige el principio de la aceptación personal, para la otra se admite la adquisición por medio de representante.

Junto a la *hereditas*, el pretor fue integrando un verdadero derecho sucesorio mediante una serie de disposiciones *edictales* y *decretales* en virtud de las cuales asignaba un señorío de hecho o *Bonorum Possessio* a personas que no siempre eran herederos de conformidad con las normas del Derecho Civil.

El pretor así como no pudo hacer crear un propietario civil o quiritario, tampoco pudo conferir el título de *heres*. Se limitó a poner una persona, *el bonorum possessor*, en posesión del patrimonio hereditario, no era un heredero, sino que ocupaba el lugar de tal (*heredis loco*). El pretor no daba la propiedad sino la *possessio* hasta que se resolviera, como se dijo la cuestión, en la *petitio hereditatis*.

En la *Bonorum Possessio* no se daba el fenómeno jurídico de la *successio*, pues el *bonorum possessor* no sustituía al difunto ocupando exactamente su lugar. No era, como el *heres*, continuador de la personalidad jurídica del causante, sino meramente un *loco heredis*. Tampoco se operaba la transmisión de la propiedad quiritaria de las cosas que formaban el acervo sucesorio, sino sólo la posesión de ellas, que podía convertirse en propiedad por virtud de la *usucapión*.

A diferencia de lo que ocurría con el sistema sucesorio de las XII Tablas, los herederos pretorios eran agrupados en varios órdenes, los cuales eran llamados sucesivamente.

Cada orden disponía de un plazo para solicitar la *Bonorum Possessio*, que era de cien días, pero se extendía a un año, tratándose de padres e hijos del causante. Si el término transcurría sin que se solicitara la *bonorum possessio*, podía hacer la petición la clase subsiguiente. El derecho pretoriano reconoció la *successio ordinum* y la *successio graduum* en el orden de los cognados.

c) Clases

a. *Bonorum possessio unde liberi*

El pretor llamaba junto con los herederos sui a los descendientes que habían salido de la potestad del causante. No entraban en este orden los que por adopción hubieran ingresado a otra familia. La adquisición de la *bonorum possessio unde liberi* requería la asignación por el pretor. Tenía carácter *cum re*, respecto de los derechos civiles.

b. *Bonorum possessio unde legitimi*

Figuraban las personas que al tiempo de solicitar el otorgamiento de la *bonorum possessio* eran llamadas a la sucesión por el derecho civil. Los *heredes sui*, seguidamente el *proximus agnatus* y en tiempos antiguos, los gentiles, se beneficiaban con este segundo llamamiento realizado por el pretor en perfecta coincidencia con el derecho civil.

c. *Bonorum possessio unde cognati*

A falta del segundo en el orden sucesorio, el pretor llamaba a suceder a los cognados o parientes de sangre más próximos. La vocación hereditaria de esos colaterales llegaba hasta el sexto grado y en la herencia de un *sobrinus* (hijo de un primo) hasta el hijo o hija del otro *sobrinus*, que está en séptimo grado. Se repartía la herencia *per capita*. El parentesco por consanguinidad podía derivar de la madre lo mismo que del padre.

d. *Bonorum possessio unde vir et uxor*

En último lugar el pretor confería la *bonorum possessio* al cónyuge supérstite. En el matrimonio *cum manu*, la mujer heredaba a su marido como *sui heredes*, porque ocupaba el lugar de hija, pero el matrimonio no tenía igual derecho respecto de su esposa. En el matrimonio *sine manu*, los cónyuges podían heredarse recíprocamente, pero heredaban sólo por virtud del otorgamiento de la *bonorum possessio unde vir et uxor*, que tenía carácter *sine re*, en defecto de cualquier otro pariente.

1) *Bonorum Possessio Decretalis*: Se otorgaba como consecuencia del imperium del magistrado en hipótesis no prefijadas en el edicto. Exigía un previo conocimiento de la causa (*causa cognitio*) o información sumaria.

a) Casos de *bonorum possessio decretalis*: Se daba sólo provisionalmente.

-*Bonorum Possessio Ventrís Nomine*: Concedida a la madre viuda que había quedado embarazada.

-*Bonorum Possessio Furiosi Nomine*: Otorgada a petición del curador del demente.

-*Bonorum Possessio Ex Edicto Carboniano*: Su nombre proviene del pretor Cneo Carbo, se confería al hijo impúber cuya legitimidad era discutida, mientras duraba la controversia.

2) Clases teniendo en cuenta sus efectos

a) *Bonorum Possessio cum re*: El *Bonorum Possessor* a quien el pretor sostenía como tal, incluso frente al heredero civil, tenía un *bonorum possessio cum re*. El magistrado corregía radicalmente al derecho civil, pues daba al heredero una posesión. En cuanto al acto de adquisición, la *bonorum possessio* no podía adquirirse *ipso iure* como la *hereditas*. Debía ser solicitada por el interesado (*agnitio bonorum possessionis*) y concedida por el pretor, no sólo cuando el caso no estaba previsto en el edicto (*bonorum possessio decretalis*), sino también cuando lo estaba (*bonorum possessio edictalis*).

b) *Bonorum Possessio sine re*: Si la posición era provisional y mante-

nida mientras no apareciera el heredero civil, a menos que se hubiera operado la usucapión a su favor, contaba con una *bonorum possessio sine re*. El magistrado confirmaba o suplía al derecho civil sin oponérsele abiertamente. Llamada *sine re* porque la concesión de la *bonorum possessio* no garantizaba quedarse con la herencia.

3) Clasificación según el modo como se confería la *Bonorum possessio*

- a) Testamentaria (*secundum tabulas*): Se llega a ésta clase de *bonorum possessio* para que se les adjudique la posesión de los bienes por un testamento irregular o írrito, excepto que le testador hubiese perdido la libertad. Se demuestra que la *Bonorum possessio*.
- a) Intestada (*sine tabulas*) no solo era modificatoria del derecho civil sino también complementaria, ya que a los *heredes* instituidos por testamento se les concedía la *bonorum possessio secundum tabulas*
- b) Forzosa (*contra tabulas*).

Ésta última especie operaba como una defensa por el pretor a favor de aquellos herederos que siendo reconocidos como tales por el edicto, hubieran sido omitidos o desheredados sin justa causa por el testador.

La petición o demanda debía formularse durante un año útil para los ascendientes y descendientes y cien días para los demás sucesores, plazos que se contaban desde que se tenía conocimiento de la muerte del autor de la sucesión. Se podía hacer la presentación por medio de representantes, posibilidad que no la cabía al heredero voluntario respecto de la *Hereditas*.

Para reclamar la posesión efectiva de la herencia concedida por el Magistrado, contaba el *Bonorum Possessor*, que no era *heres* ni disponía de la *petitio hereditatis*, con un interdicto restitutorio designado con el nombre de *quorum bonorum* por las palabras con que comenzaba la fórmula.

XVII. Sucesión del derecho imperial

- a) El *Senatusconsultum Tertullianum*, en la época del emperador Adriano, concedió a las madres que gozaran del *ius liberorum*, el derecho de suceder a sus hijos en la clase de agnados.
- b) El *Senatusconsultus Orfitianum*, dictado en el año 178 bajo el gobierno del emperador Marco Aurelio, dispuso que los hijos sucedieran a la madre con exclusión de los consanguíneos y además agnados de aquélla.
- c) Constituciones Valentiniana y Anastasiana

Por disposición del emperador Valentiniano II los nietos sucedían, junto con los hijos y los agnados, a la abuela paterna y a los abuelos maternos.

Por obra del emperador Anastasio, la cognación se impuso también en la línea colateral y se dispuso que podían suceder entre sí los hermanos y hermanas emancipados, junto con los no emancipados, aunque no por partes iguales, sino en porción menor que estos últimos. La restricción fue abolida por Justiniano.

- d) ¿En qué aspectos influyó el senadoconsulto?

La Ley Julia y Papia Poppaea, de la época de Augusto otorgaban beneficios o premios por decirlo de alguna manera a los que tenían hijos, mientras imponía penas a los que carecían de ellos; el senadoconsulto Tertuliano dado bajo el reinado de Adriano, confería la herencia del hijo a la madre que gozara del *ius liberorum*, el nacimiento de un hijo póstumo, acarreaba la caída del testamento.

Las cuestiones planteadas llevaban a decidir si el nacido muerto, o el nacido con vida, pero sin contar con la forma humana podía considerarse como hijo. La contestación fue negativa con relación al hijo nacido muerto. El monstruo o prodigio se computa a los efectos de la ley Julia y Papia Poppaea, pero no con relación al senadoconsulto Tertuliano.

En cuanto a la ruptura del testamento, por nacimiento de un póstumo, se discute si el aborto puede o no determinarla, proclamándose

por la afirmativa Ulpiano y por la negativa una constitución de Maximiano y Diocleciano.

Gaius en sus Instituciones hizo referencia a éste senado-consulta, por el cual se permitió a las mujeres pupilas hacer testamento aún sin la coemptio, con tal de que no fueran menor de doce años, se entendía que aquellas que no fueran liberadas de la tutela, deben estar con la auctoritas del tutor.

Se ve así que las mujeres se encuentran en mejor condición que los varones, ya que el varón menor de catorce años no puede hacer testamento, ni aún si quisiera hacerlo con la auctoritas del tutor; la mujer en cambio, después de los doce años le asiste el derecho de testar.

En el año 528 suprimió Justiniano el *Ius Liberorum*, consagró a favor de la madre el derecho de suceder al hijo aun cuando tuviera uno solo, dándole preferencia sobre los colaterales a excepción de los hermanos del causante con quienes debía dividir la herencia per cápita.

Sin embargo mantiene la exclusión de la madre en la sucesión del hijo cuando éste tuviere herederos suyos o padre natural.

XVIII. Sucesión del derecho Justiniano. Novelas 118 y 127

En el año 543 el emperador Justiniano sanciona la Novela 118, que se completa con la Novela 127 sancionada en el año 548. Por ellas se sistematiza el derecho sucesorio intestado y se dejan sin efecto las creaciones de la costumbre. Así, la primacía del parentesco natural sobre civil o agnaticio, con la distribución de los parientes de sangre en tres órdenes de sucesibles: los descendientes, los ascendientes y los colaterales.

Las Novelas 118 y 127 comprendieron los siguientes órdenes con respecto al régimen hereditario ab intestato: descendientes; ascendientes y hermanos y hermanas carnales o doble vínculo (*germanicus*) y sus hijos; hermanos y hermanas de padre (*consanguinei*) o madre (*uterini*) y sus hijos; otros colaterales hasta sexto o séptimo grado.

XIX. Sucesión intestada en orden a los libertos

La sucesión intestada del liberto varió en Roma según las épocas y los ordenamientos que la regularon.

La Ley de la XII Tablas, atendiendo que el liberto carecía de parientes agnados, llamaba a heredarlo, cuando hubiera muerto sin herederos sui, al patrono y en su defecto a los sui del patrono, e incluso sus agnati o gentiles. Al liberto se equiparaba al hijo emancipado, que había sido manumitido por su padre (*manus manumissor*) en la solemnidad de la antigua emancipación.

El pretor no podía realizar en la herencia del liberto una promoción de los cognados en la misma medida que en la del ingenuo, porque había nacido esclavo carecía de cognación, siendo la suya sólo una *cognatio servilis*, fundada en el contubernio, no en el matrimonio. De ahí que en lugar de los cognados del liberto, sucediera el patrono con sus descendientes y demás parientes. Constituía un caso especial la Bonorum Possessio por muerte del emancipado.

En la sucesión de los libertos fue teniéndose en cuenta el parentesco de sangre creado por la esclavitud, limitándose el derecho a heredar del patrono y de sus parientes a favor de los padres y parientes del liberto, siempre que gozan de libertad.

En el derecho justiniano, se estableció en cuanto a la sucesión del liberto el siguiente orden: descendientes del liberto; patrono, hijos naturales del patrono y colaterales hasta quinto grado; colaterales del liberto hasta el quinto grado y. Por último, cónyuge supérstite.

XX. La Cretio y la Pro herede Gestio

Según Sabinus en tanto en que el instituido en primer lugar esté en el tiempo de la opción y de éste modo poder ser heredero, el substituto por más que obre como heredero no puede, sin embargo, ser admitido como tal; en cambio si el plazo de la *cretio* se ha terminado y el substituto se comporta como heredero, entonces es admitido como tal. Para otros por el contrario, aun cuando no hubiese finaliza-

do el plazo de la *cretio*, siempre que el substituto se hubiese comportado como heredero, y entonces la *cretio* no puede tener lugar.

Esta discusión va a ser decidida por medio de una constitución de Marco Aurelio, quien dispuso de acuerdo con Sabinus, que el instituido heredero con una *cretio* imperfecta, si realizaba la *pro herede gestio* durante el plazo, obtenía el total de la herencia y por supuesto que una vez vencido dicho plazo si no hacía la *cretio* ni la *pro herede gestio*, entonces la herencia pasaba al substituto.

XXI. El Legado

De las definiciones más citadas de *Legatum* es la de Ulpianus, es lo dejado en un testamento de forma legal, es decir en forma imperativa, ya que si la dejáramos en forma de ruego, entonces es llamado *fideicomisso* y no sería legado.

Legamos *per praeceptionem* de éste modo: “Que Julio reciba por adelantado a mi esclavo”.

La fórmula empleada, de acuerdo con Ulpianus. En ésta clase de legados encontramos dos concepciones:

- a) La de los sabinianos, que considera que solo pueden ser legatarios *per praeceptionem* los co-herederos y;
- b) la de los proculeyanos que consideran que puede ser un extraño.

De acuerdo a lo señalado en las fuentes, los llamamientos a la *bonorum possessio* del liberto ciudadano romano son en la época clásica:

- a) *unde liberi*, sui herederos del liberto;
- b) *unde legitimi*, son los herederos civiles: patrono, patrona y descendientes del patrono;
- c) *unde cognati* o cognados del liberto;
- d) *tum familiae patroni*, son los demás familiares civiles del patrono no incluidos en el segundo llamamiento;
- e) *patronus patronae item liberi patronaeve*, se refiere al supuesto del patrono manumitido que por ello mismo él se encuentra como liberto sujeto a un extra patrono;

- f) unde vir et uxor o cónyuge supérstite del liberto;
- g) unde cognati manumissoris o parientes cognados del patrono.

La estricta observancia de ésta formalidades en la celebración del testamento, ha sido dispensada a los militares en las constituciones del príncipe, a causa de su gran inexperiencia. Así aunque no hayan presentado el número legítimo de testigos, ni hayan “vendido” la familia, ni hayan nuncapado el testamento, éste no por ello dejará de ser válido.

El primero en conceder éste tipo de ventajas a los militares fue Julio César, pero ello solo fue por un tiempo determinado, luego fueron los emperadores Titus, Domiciano, Nerva, y finalmente por mandatos a los gobernadores de provincia, Trajano.

XXII. Donación mortis causa.

Se trata de donaciones por causa de muerte. Así, cuando alguien teme una muerte inminente, dona: p.ej., un fundo para cuando efectivamente muera. De este modo, si el donante ha logrado salvar el peligro de muerte, o también si el beneficiario ha premuerto en relación a él, la donación cae por haber fallado la causa.

- a) La donación mortis causa podía estar subordinada a la muerte de dos maneras distintas. Así, entregando la cosa donada, pero de tal modo que el beneficiario no se hiciera propietario de ella sino luego de la muerte del donante. Se trataría de una condición puramente suspensiva, de tal modo que si ocurriera la muerte, la propiedad se adquiriría directamente. Si no ocurría o premoría el beneficiario, el donante puede ejercer la rei vindicatio, puesto que la cosa no ha dejado de ser suya. Y también transfiriendo directamente la propiedad de la cosa donada, pero con la condición de que se le será devuelta si no ocurre la muerte, o si premuere el beneficiario. Aquí estamos en presencia también de una condición suspensiva, pero con

- efectos resolutorios. El donante puede demandar la devolución de la cosa por la *condictio* (*ob causam, ob rem datam*).
- b) La donación *mortis causa* se consideró que era perfecta e irrevocable por la ocurrencia de la muerte. A partir de la época posclásica, criterio que mantiene Justiniano, se lo consideró revocable por el propio donante en vida.
 - c) Esta clase de donaciones tenía la ventaja de poder disponer cosas para después de la muerte, evitando ciertos inconvenientes que podía tener hacerlo por testamento. Pero ya desde la época clásica no dejó de sorprender a los juristas la semejanza que, por lo menos desde el punto de vista económico, tenían las donaciones *mortis causa* con los legados.
 - d) Finalmente Justiniano, por una constitución especial, termina por asimilar las donaciones *mortis causa* a los legados “surtiendo todos los efectos que tienen éstos, y no se entienda que en alguna cosa es diferente de ellos”.
 - e) La denominación de *mortis causa capiones* (adquisiciones *mortis causa*) resulta en principio muy amplia y abarca todo aquello que se adquiere a título hereditario, o por legado, o por fideicomiso, y también por una donación *mortis causa*. Pero, con un sentido más restringido, sirve para designar todo aquello que se adquiere por causa de herencia que no esté comprendido en los supuestos ya mencionados “que tienen nombre propio”. Así, sería el caso de lo que el esclavo manumitido por testamento, o el legatario queda obligado a pagar al heredero para cumplir la condición que le fue impuesta por el testador.

XXIII. Nociones históricas sobre sucesiones entre cónyuges

Debido al arraigado prejuicio de que los bienes del difunto debían conservarse dentro del ámbito de su procedencia, el antiguo derecho prácticamente ignoró la sucesión entre cónyuges. Aparte de que la mujer era relegada de la vida jurídica, quedando bajo la potestad pa-

terna se ligaba al marido por lazos parecidos a los que se encontraba cuando quedaba bajo la potestas del pater.

La comunidad de sangre, base de la transmisión hereditaria inexistente entre cónyuges, quería consolidarse en el no traspaso a otros grupos familiares.

Con el paso del tiempo, estos prejuicios en relación al rol que debía jugar la mujer dentro de la vida social y familiar, se flexibilizaron con la permisión jurídica que autorizaba a los cónyuges a sucederse recíprocamente.

XIV. Protección procesal del heredero

1) “*Actio petitio hereditatis*”

Al interponer la acción el *heres* afirmaba su calidad de tal y perseguía la devolución de los bienes hereditarios contra cualquiera que los poseyera ya sea a título de heredero ya sea como simple poseedor (*bonorum possessio*). La acción de petición de herencia perseguía la restitución del patrimonio del causante en el sentido más amplio, con todos los incrementos que hubiera tenido, en especial en los frutos producidos.

2) Interdictum quorum bonorum

El *Bonorum Possessor*, al no tener calidad de heredero, y no disponer por tanto de la propiedad *ex iure quiritium* de la *hereditas*, no disponía de la *petitio hereditatis*, pero el pretor le concedió un interdicto restitutorio, para reclamar la posesión efectiva de la herencia concedida por el magistrado. Cuando se dirigía contra un heredero civil, podía éste insertar una excepción fundada en su calidad de tal, pero si se trataba de una *Bonorum Possessio cum re*, el *bonorum possessor* disponía de una réplica que podía alegarse como excepción en el caso de que el *heres* entablara la *petitio hereditatis* contra el heredero que estuviera en posesión de los bienes.

Éste interdicto era oponible, no sólo al que poseía pretendiendo ser heredero (*possessor pro herede*), sino también al que simplemente

se opusiera a la restitución, sin alegar un propio derecho (*possessor pro possessore*).

Era también ejercitable, contra el que hubiera dejado de poseer por dolo (*qui dolo desiit possidere*). El pretor concedió al *bonorum possessor* un interdicto llamado *quod legatorum*, para oponerlo al legatario que tomaba posesión de los objetos legados antes de que le fueran entregados.

FRANJA
MORADA

I. Hechos y Actos jurídicos

Para el desarrollo de los temas que a continuación se expondrán es menester hacer algunas aclaraciones.

Las denominaciones que se utilizarán responden a elaboraciones modernas del derecho, que si bien fueron concebidas por los romanos y que sí existieron en cuanto a su naturaleza jurídica y aplicación práctica no las conocieron tal como las estudiamos en la actualidad, dicho de otra manera, el negocio jurídico es una construcción jurídica posterior al Derecho Romano puro.

Para definir que es un negocio jurídico, primero tenemos que saber qué es un hecho, es algo que acontece, ya sea por la intervención humana o por la intervención de elementos de la naturaleza.

Hecho es algo con lo que debemos convivir a diario, y en muchos casos no tienen mayor trascendencia, sin embargo se plantean determinadas situaciones en las que debe intervenir el derecho para que haya entre los individuos de una sociedad una convivencia pacífica.

Si tomamos un hecho de la naturaleza como puede ser el vuelo de las aves, puede pasar hasta desapercibido para muchas personas, sin embargo, los pontífices le daban trascendencia jurídica, interpretaban la voluntad de los dioses y si contaban con su aprobación, se podía celebrar, por ejemplo, una compraventa, así vemos como a un hecho de la naturaleza se le daba una interpretación jurídico-religiosa, me estoy refiriendo a una época en la que el derecho se hallaba bajo la influencia del fas, pero de su consecuencia dependía la validez del acto jurídico. El que acabamos de ver es un ejemplo de lo que ocurría en una época muy primitiva; pero sin embargo cuando el derecho se hace laico, los hechos de la naturaleza van a ir repercutiendo en el derecho pero de otra manera, el nacimiento de un animal en principio es solo eso, pero es un bien que va a incrementar un rebaño y por ende el valor patrimonial será otro, así apareció en Roma la regulación de las cosas, los frutos, el dominio, el condominio, la posesión, y otros derechos reales en general, que van a regular desde el derecho los vínculos entre las cosas y las personas.

También hay otras situaciones, en las que no intervienen hechos de la naturaleza que van a tener consecuencias jurídicas, sino que intervienen hechos que se dan por el acuerdo o consenso de los hombres para realizar tal o cual acto que al estar regulado por las leyes van a tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo: dos partes a las que el derecho denomina deudor y acreedor que contraen una obligatio, y se compromete el primero a cumplir su prestación en una época determinada.

De lo expuesto surge entonces: Que hay hechos en los que interviene la naturaleza y hechos en los que interviene la voluntad del hombre, en el primer caso podrán traer o no consecuencias jurídicas, y en el segundo caso si está regulado por el derecho se tratará de un acto jurídico.

Cuando hablamos de los actos jurídicos éstos se llevarán a cabo por las partes de acuerdo con las pautas establecidas por el derecho, entonces los actos serán lícitos: Sempronio contrae matrimonio con

Ticia porque cumplen con los requisitos de la edad, del *connubium* (capacidad jurídica para contraer matrimonio), los *patres* respectivos han dado su consentimiento para llevar a cabo el acto, son púberes, y dan su consentimiento, en cambio si el acto del matrimonio se lleva a cabo transgrediendo lo dispuesto por las normas: por ejemplo que Ticia sea tomada por la fuerza y bajo amenazas se lleve a cabo el acto, el matrimonio será llevado adelante como un acto ilícito, careciendo de eficacia jurídica por la lesión a un requisito esencial como lo es el consentimiento de los contrayentes.

También podía ocurrir que se suscitara alguna cuestión entre los particulares que el derecho no los regulara, como ocurre en todo ordenamiento jurídico que no está exento de los vacíos legales, entonces las partes para llevar adelante alguna cuestión y resolverla deberán atenerse a lo dispuesto por los principios generales del derecho que se hallaban en la buena fe, la costumbre y la equidad, porque, la ausencia de regulación es motivo de resolución por parte de los magistrados, con criterios de interpretación basadas en los parámetros mencionados, a los fines de que las partes no resultaran perjudicadas y hubiera un justo equilibrio, tales aspectos se manejan dentro de la licitud. Nadie podrá perjudicar a otro excusándose en que la cuestión no está regulada por el derecho.

Cuando me refiero a los actos ilícitos, quedan comprendidos los delitos pero no como sinónimos sino como un sub grupo dentro de la categoría de los actos ilícitos.

II. Clasificación de los Actos Jurídicos

A) Actos jurídicos unilaterales y bilaterales

En los primeros tiene que existir una sola manifestación de voluntad: por ejemplo el testador cuando instituye un heredero, no es necesario que éste dé su consentimiento, incluso puede ocurrir que no esté enterado, sin embargo la sola manifestación de voluntad hace que el acto sea válido.

En cambio en los segundos será necesario indefectiblemente la intervención de dos o más voluntades que plasmarán su consentimiento para que un acto jurídico sea válido debido a que hay actos cuyas características particulares hacen que se lleve a cabo de la manera descrita: por ejemplo, el matrimonio, una compraventa (tiene que haber necesariamente un comprador y un vendedor).

B) Solemnes y no solemnes

En los primeros el derecho establece el cumplimiento de formalidades que eran necesarias llevar a cabo para que el acto fuera plenamente válido, por ejemplo en los actos que se realizaban por el ritual del cobre y la balanza era necesaria la presencia del *libripens*, los testigos, y la pronunciación de palabras solemnes por parte de los intervinientes.

En los segundos no se requiere el cumplimiento de formalidades debido a que ésta cuestión responde a que nos encontrábamos en una etapa del derecho en que no era necesario el cumplimiento de formalidades o solemnidades que se requerían en los tiempos primitivos, característica de la época en que el derecho se hallaba bajo la influencia del *fas*. Por ejemplo: *la sponsio*: Era un contrato verbal que simplemente consistía en una pregunta y en una respuesta.

C) Onerosos o gratuitos

En los primeros el acto jurídico se realiza a cambio de una contraprestación valorada económicamente. Por ejemplo: En el caso de la locación, el pago del precio de la misma denominado alquiler por parte del locatario.

En cambio en los segundos, una de las partes realiza algo que pactó previamente con otra pero no recibe a cambio una contraprestación como en el caso anterior. Por ejemplo: Varrón le dona a Sempronio un fundo y veinte esclavos, sin obtener nada a cambio del segundo.

D) Causales o abstractos

En los primeros la causa aparece unida a la existencia del negocio, ej. La compraventa en la cual el fin tenido en vista es inseparable de aquella.

En los segundos lo que interesa es la realización de las solemnidades sin tener en cuenta el fin tenido en vista. La importancia de esto radica en el primero ya que si el negocio es causal y la causa es ilícita, ello arrastrará la nulidad del mismo.

E) Inter vivos o mortis causa: los primeros son aquellos que tienen eficacia en vida de las partes. Por ejemplo una locación o una compraventa.

En cambio los segundos tendrán plena validez después de acaecida la muerte de alguna de las partes, por ejemplo: después de la muerte del causante, y luego de la aceptación de la herencia el heredero podrá cumplir con el legado de cinco esclavos que el de cujus dejó a Sempronio.

III. Concepto de Acto o Negocio Jurídico

De lo visto se desprende que el negocio o acto jurídico se trata de un acontecimiento que al llevarse a cabo produce consecuencias jurídicas para alguien, el efecto que produce es el nacimiento, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas, para alguien constituyéndose como una declaración de la voluntad dirigida a obtener un fin práctico, económico o personal, y que el derecho reconoce.

Si bien es conveniente por una cuestión práctica tomar al negocio y al acto jurídico como sinónimos no se puede dejar de mencionar que algunos estudiosos han considerado que en el acto la manifestación de voluntad se encuentra restringida, mientras que en el negocio es más amplia las intervenciones que las partes pueden tener, de acuerdo a las permisiones de la ley.

A partir de la definición del negocio jurídico, se desprenden los elementos que son necesarios que tenga para que el acto que se celebre tenga plena validez jurídica.

IV. Elementos del negocio jurídico

A) Elementos Esenciales

Hay elementos cuya existencia es vital para el nacimiento de un negocio jurídico sin ellos serán inexistentes. A éstos se denominan elementos esenciales, si no están o están pero viciados, el acto o negocio es nulo.

B) Clases

1) Las Formas en que se puede manifestar la voluntad

La voluntad se puede manifestar de manera expresa o tácita. Es expresa cuando se formula verbalmente, o por escrito, o por signos inequívocos, éstos son los que no dejan dudas acerca de lo que se pretende manifestar, por ejemplo recordemos que entre las potestades del pater está aquella por la cual incorporaba la recién nacido a la familia, para ello se lo debía poner primero en el piso y éste lo tomaba en sus brazos, no pronunciaba palabra alguna, pero era un acto con gran trascendencia jurídica.

También podía ser Tácita era cuando no había signos expresos de cuál era la voluntad de las partes, no porque no la hagan sino porque lo hacían de manera presunta, por ejemplo que el heredero designado por Ticio se haga cargo de las deudas de éste a su muerte. Otro ejemplo es cuando el pater no puede hablar y al no poder hacer uso de la palabra manifiesta de otras formas su intención de dar a su hijo en adopción se confirma ésta como si fuera hecha según la forma que previene el derecho ello es así debido a la importancia que se le daba a la manifestación del consentimiento expreso.

En cuanto al Silencio, en casos muy excepcionales se constituyen como manifestación de la voluntad, buscar casos de silencio.

2) El Objeto

Es el elemento sobre el cual recae el negocio jurídico. Debe reunir determinados requisitos:

- a) Ser lícito: Su nombre lo refiere claramente, no debe ser contrario al derecho, a la moral y a las buenas costumbres.
- b) Debe ser Posible: no solo desde el punto de vista práctico y real, o sea, sino también debe serlo desde el punto de vista jurídico, se complementa así con la licitud.
- c) Debe ser determinado: Por lo general el objeto debe ser señalado por las partes al comienzo del negocio jurídico, sin embargo se admitió excepcionalmente que al hacerse una referencia genérica al objeto en el momento del nacimiento del negocio ésta cuestión daba lugar a la existencia de la “indeterminación” que posteriormente era desvirtuada por la “determinación” que hacía la parte cumplidora al momento de entregar el objeto, si esto no pudiera llevarse a cabo de la forma planteada dificultaría la concreción de muchos negocios, por ejemplo: Ticio le dice a Sempronio que le va a entregar como pago los animales que nacieran hasta llegada la fecha 20 de abril, ello depende de que se produzca el nacimiento y no aparezca una circunstancia extraordinaria que impidiera el mismo como lo sería una enfermedad que afecte al ganado y lo mate, dicho de otra manera el cumplimiento está supeditado a una condición que es la producción del nacimiento, situación en la que el objeto se convierte en determinado.

3) La Causa

Se halla en ella la motivación de la celebración del acto jurídico que se quiere llevar a cabo, es tenido en cuenta en caso de que surjan conflictos con respecto al acto que se quiso celebrar.

4) La Forma

Se trata de un elemento fundamental dado que la ley influenciada por la religión exigía el cumplimiento de determinadas solemnidades, como podía ser la pronunciación de palabras solemnes, celebrar el acto jurídico en cuestión un día fasto, golpear el cobre en la balanza en el caso de los actos *per aes et libram*, solo por mencionar algunos.

C) Elementos naturales

A diferencia de los elementos esenciales no resultan necesarios para concebir el negocio jurídico pero están en la naturaleza misma de éste. Las partes pueden ponerse de acuerdo para dejarlas de lado.

- a) Ellos son los vicios redhibitorios, se refiere a los vicios ocultos que la cosa pudiera tener, por ejemplo que haya canillas y no haya una red de instalación de agua. Es lo que no se puede ver a simple vista y quién lo calló deberá responder legalmente.
- b) Las garantías de evicción, por ella el transmitente le asegura a su contra parte en el negocio de que goza de las garantías que no existen conflictos de índole alguna que le turben su derecho sobre la cosa que adquirió.

D) Accidentales

Son aquellos que pueden incorporarse en el negocio jurídico, pero que su existencia no se presume, sino que depende de la voluntad de las partes que las hayan o no querido incorporar.

Son la condición, el plazo o termino, el modo o cargo.

- a) condición: es un acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende el negocio jurídico. Así por ejemplo si establezco “prometes darme cien sestercios si llueve” el negocio depende de que se cumpla la condición. las condiciones se pueden agrupar en:

- 1) **Suspensivas o resolutorias:** se dice que una condición es suspensiva cuando la realización del acontecimiento futuro e incierto determina el nacimiento del negocio. se dice que una condición es resolutoria cuando de suceder el acontecimiento se produce la extinción del negocio. (Suspensivas: prometes darme cien si viene mi hijo de Italia).
- 2) **Resolutorias:** Pone fin a algo, por ejemplo: en virtud de una compraventa se tiene por no hecha, si el vendedor dentro de un tiempo recibe una oferta mejor.
- 3) **Positivas o negativas:** en las primeras se produce el negocio si se realiza el acontecimiento futuro e incierto; “te daré 100 si hoy viene Cornelius a visitarme” en las segundas se produce el negocio si no se produce el acontecimiento; “te daré 100 si hoy no viene nadie a verme”.
- 4) **Posibles o imposibles:** la condición es imposible cuando el acontecimiento no se puede realizar a causa de un obstáculo que puede ser físico o jurídico; así es físicamente imposible “te prometo cien si puedes volar con los brazos” y es jurídicamente imposible “te prometo 100 si vendes templo de la diosa Vesta), porque no se pueden vender las cosas sacras.
Lícitas o ilícitas: son ilícitas aquellas contrarias al derecho “te daré 100 si envenenas a Sempronio”.
- 5) **Causales, potestativas y mixtas:** son causales aquellas condiciones que dependen de un evento de la naturaleza o de un tercero “te daré 100 si llueve”. son potestativas, cuando dependen del querer de la parte interesada “te daré 100 si llevas los materiales”. Son mixtas, cuando dependen de un tercero y del querer de la parte “te daré 100 si van con Ticio a buscar materiales”.
- b) **El plazo o término:** es el acontecimiento futuro y objetivamente cierto del cual depende que un negocio jurídico nazca o se extinga. **Modo o Cargo:** sirve para designar una cláusula agregada a los actos de liberalidad, como los legados, donaciones, por ejemplo en los que se le impone al destinatario del beneficio gratuito un com-

portamiento determinado “Que a mi muerte mi heredero Sempronio entregue cinco esclavos a Ticio”.

V. La Interpretación del negocio jurídico

Cuando se suscita alguna cuestión que hay que resolver el negocio jurídico debe ser interpretado con el objeto de determinar cuál es el contenido y su extensión.

Hay circunstancias en las que es necesario determinar qué es lo que se dijo o manifestación de la voluntad objetiva y el eventual divorcio o no que pueda haber con lo que en realidad se quiso decir o manifestación de la voluntad subjetiva.

De estos dos aspectos se originan dos posturas o criterios:

- 1) De acuerdo con la manifestación de la voluntad como hecho interno, denominado voluntarista: si la declaración es susceptible de más de un sentido, el intérprete debe determinar hasta donde sea posible cual fue la voluntad del declarante. Este criterio corresponde a postura de la interpretación subjetiva.
- 2) De acuerdo con la voluntad como hecho manifiesto y externo, denominado declaracionista: hay que atenerse únicamente a la voluntad declarada, interpretándola de manera aislada de las motivaciones internas del declarante. Este criterio corresponde a la línea de interpretación objetiva.

En los orígenes del derecho romano, la interpretación era de carácter objetivo pero luego en el *ius gentium*, al dejarse de a poco las solemnidades se aparece una amplitud interpretativa, dándosele prioridad a la voluntad intrínseca que tuvo el sujeto cuando entabló el negocio.

La forma de interpretación subjetiva le daba al pretor amplias posibilidades de interpretación. El caso más conocido fue la Causa Curiana del siglo I a. C., un juicio que se presentó ante el Tribunal de los *Centumviri*, se planteó el caso de una persona que hizo su testamento y esperando que la mujer la diera un hijo lo instituyó su heredero, previendo que pudiera nacer después de su muerte; a su

vez estableció una cláusula que se conoce como sustitución pupilar que fijaba la posibilidad de que el hijo falleciera antes de alcanzar la pubertad, el heredero pasara a ser M. Curio.

El hijo no nació entonces se planteó una controversia entre los herederos, Coponio, y Curio,

- a) El primero representado por Quintus Muscius Scaevola, argumento sobre una fórmula declaracionista objetiva: se basó en que no habiendo nacido el heredero instituido, en realidad no había heredero y por lo tanto no había testamento.
- b) El segundo, representado por Licinnio Craso, argumento interpretación voluntarista subjetiva: se basó en que la voluntad del testador estaba manifestada por la adición de su sustitución pupilar, en que quedaba evidenciado el interés de que la herencia no pasara a sus agnados.

La causa fue juzgada por el tribunal de los centumviro y se inclinó por curio, interpretando la voluntad del causante por encima de lo literal.

VI. Ineficacia en los negocios jurídicos. Clase. Causas

Existen dos supuestos:

- a) el caso de la nulidad, en el cual el negocio jurídico tiene apariencia de ser, pero carece de algunos elementos esenciales razón por la cual se lo considera inexistente o inválido;
- b) en el caso de la anulabilidad en el cual el negocio existe y en principio produce los efectos jurídicos que se propusieron las partes, pero estas pueden pedir su anulación o decretarla el juez en caso de un obstáculo jurídico existente.

En el viejo ius civili los negocios son susceptibles de nulidad y no de anulabilidad que se aplicara luego en el ius gentium.

VII. Vicios de la voluntad: en las causa de anulabilidad, se dan tres casos; error; dolo; violencia.

A) Error: es el falso conocimiento que las partes tienen del negocio o sobre un aspecto del mismo. Este es el error de hecho.

- 1) Existe el error de derecho que es la ignorancia del conocimiento de las reglas jurídicas o el conocimiento equivocado de estas. El error de derecho es inexcusable salvo para los menores de 25 años, las mujeres, los soldados.

El error puede versar sobre el negocio o sobre distintos aspectos de él.

- 2) Error in negotio existe un desacuerdo total entre lo que las partes han querido celebrar y lo realmente celebrado. Ocurre, si Ticio, cree haber dado una cosa en virtud de una compraventa, y Sempronio, cree haberla recibido en carácter de donación. No se produce el negocio.
- 3) Error in persona: Tiene lugar cuando se ha realizado el negocio con una persona distinta de aquella con la cual se ha querido celebrar el mismo.
- 4) Error in corpore: tiene lugar cuando se ha realizado el negocio sobre un objeto distinto del que creía celebrarlo. “Así, creo haber comprado el campo A y resulta que me han vendido el campo B”.
- 5) Error in sustancia: tiene lugar cuando recae sobre las características esenciales del objeto del negocio. “Así, por ejemplo, creo comprar una botella de vino y en realidad contiene vinagre”.
- 6) Error in quantitate: tiene lugar cuando recae sobre la cantidad del objeto. “Así, creo comprar 10 caballos, y en realidad la otra parte me ha vendido solamente 5”.

B) El dolo

Es toda clase de maniobra o manipulación engañosa que tiene como objeto provocar un estado de error en la otra parte con la cual se realiza el negocio. Se trata acá no de un error involuntario sino de un error provocado. Esto sería para los romanos un dolo malo, pero

también diferenciándose de esta definición estaba el dolo bueno, que eran normales artificios utilizados en los negocios.

a) Requisitos para que haya dolo

- 1) el dolo debe provenir de la contraparte comercial y no de un tercero.
- 2) las maniobras dolosas deben haber sido causa determinante de la realización del acto.
- 3) debe ocasionarse un daño importante de carácter patrimonial.
- 4) no debe mediar dolo de ambas partes.

C) Violencia

En la violencia física alguien fuerza a otro a realizar un acto en contra de su voluntad, la consecuencia es que el mismo no trasciende a la vida jurídica el negocio por la falta de voluntad de la parte forzada.

En la violencia moral, se lleva a cabo un negocio por la coacción que alguien ejerce sobre la parte afectada en contra de su voluntad y obligarla a hacer algo que no quiere como en la violencia física.

Si se pretende la restitución delo entregado por miedo o el cuádruplo de su valor.

Para poder argumentar violencia se necesitan estos requisitos:

- 1) debe haber una amenaza injusta, es decir, el preannuncio de querer hacer sufrir a otro un mal. No es injusta la amenaza hecha del deudor de demandarlo ante la justicia. No interesa si la amenaza proviene del que tiene interés en el negocio o de un tercero
- 2) el mal con que se amenaza debe ser grave o inminente.
- 3) debe estar dirigido a que la persona amenazada tenga que realizar el negocio jurídico.
- 4) la amenaza debe ser seria, capaz de impresionar a una persona.

Los derechos patrimoniales

I. El patrimonio. Concepto

Patrimonium es lo recibido por el pater.

Un concepto que se le aproxima es el de pecunia: comprende las cosas corporales, los derechos y las obligaciones.

Dicho de otra manera es el conjunto de cosas que pertenecen a un sujeto que tiene la titularidad, son una universalidad jurídica, compuesto por las cosas materiales e inmateriales, (bienes, créditos, derechos, acciones) por ejemplo: un esclavo y una servidumbre. Para ser titular un patrimonio había que tener capacidad jurídica. Comprenden el concepto de patrimonio: la sucesión a título universal, la separatio bonorum, el beneficio de inventario.

Derechos reales y de crédito

Los derechos reales establecen vínculos entre las personas y las cosas. De éstos vínculos las acciones de reclamos que se puedan presentar posteriormente pueden ser in rem o un personam.

Son *in rem* las acciones relacionadas con la protección de los derechos reales, el objetivo es la res o cosa y su eventual obtención, restitución de quién la tuviese en su poder. El titular del derecho exige de la contraparte que se comprometió en el vínculo obligacional, ésta responsabilidad no se traslada a otro sujeto. Por ejemplo en los préstamos dinerarios o mutuo se le va a exigir la devolución del préstamo a quién se le ha realizado y no a un tercero.

Son *in personam* las relacionadas con exigirle a la contraparte que cumpla con lo que se había comprometido. Por eso se aplican a la protección de los derechos subjetivos obligacionales. El acreedor puede exigirle al deudor una obligación de dar, hacer o no hacer. Por lo tanto se tratan de conductas positivas o negativas.

II. Las cosas. Concepto

Res en un sentido amplio es la cosa, por ejemplo: un esclavo, un fundo. Es todo lo que existe fuera del hombre libre. Comprende las relaciones patrimoniales en las que intervienen los sujetos y las cosas. No solo las materialidades sino también lo inmaterial, en éste último caso se trata de las cosas inmateriales, no pueden palparse o tocarse como los derechos o las obligaciones, en éste último caso no se refiere a la obligación de entregar una cosa que se puede ver o tocar, sino a la inmaterialidad del vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor.

La cosa es una entidad, aquello a los que los sujetos le han asignado un valor de carácter patrimonial. El fundamento del valor se encuentra en la utilidad, fin o servicio que presta, y sus características o condiciones de apropiación y pertenencia para un sujeto. Los vínculos entre las cosas y los sujetos están regulados por el derecho.

Desde otra perspectiva, también cosa o res se puede referir en un sentido amplio a bienes: materiales e inmateriales.

Categorías

Res Divini Iuris: Res sacrae (vasos sagrados); Res religiosae (sepulcros); Res Sanctae (muros de las ciudades).

Res Humani Iuris: Res Comunes (aire, sol); Res publicae (caminos, ríos, etc); Res Universitatis (personas morales); Res Privatum: (patrimonios particulares).

Res extra commercio

Comprende a las cosas susceptibles de ser objeto de relaciones jurídico-patrimoniales, porque así lo establece el fas o derecho religioso y establecido por ley positiva. Comprende:

Res divini iuris

Son las consagradas a los dioses, no pueden ser objeto de relaciones patrimoniales. Estaban sometidas a la autoridad de los pontífices.

Esta categoría se encuentra integrada por las res sacrae, las res religiosae y las res sanctae.

Res sacrae

Son las consagradas a los dioses superiores (templos, altares, bosques sagrados), eran los que habitaban en el cielo, se hacía por medio de una consecratio de los pontífices concurrente con el consenso del populus (ley, plebiscito o senadoconsulto; en períodos del imperio: de una constitución).

Las cosas sagradas solo pierden su carácter después de una ceremonia religiosa destinada a hacerlas profanas. Eran inalienables. La violación de una res sacrae estaba sancionada por el interdicto ne quid in loco sacro fiat y constituía un crimen.

Res religiosae

Eran aquellas destinadas al culto de los dioses inferiores (manes), el terreno situado en el *ager romanus privatus*, en el que su propietario enterró a un hombre, sea libre o esclavo, pero no el de un enemigo del pueblo romano, y en que se construía su monumento funerario.

También podía haber *res religiosae* afuera de las ciudades, hacer inhumaciones en el interior de las ciudades.

A pesar del estar fuera del patrimonio de los particulares y eran inalienables los miembros de una familia o de una *gens* tenían el derecho de ser enterrados en una misma sepultura, transmitiéndose este derecho hereditariamente. La cenotafio (tumba vacía no se consideraba una *res religiosae*). En cambio sí se las consideraba con ese carácter a las tumbas de los esclavos, después de muerto no se lo considera *res*. Si alguien pretendía hacer una exhumación sin permiso del pontífice o del Príncipe, se concedía al propietario una *actio in factum* para hacerse indemnizar en caso de que ocurriera tal cuestión.

Res sanctae

Son las cosas puestas bajo la protección de los dioses mediante la ceremonia de la *sanctio*, se asimilan a las *res divini iuris*, aunque no están consagradas a los dioses. A tal clase pertenecen los muros y las puertas de las ciudades, a quien las violara se les aplicaba una pena una pena capital, por ejemplo cuando se le dio muerte a Rómulo por violar los muros de la ciudad (leyenda). Son las cosas que pertenecen a la divinidad y están protegidas contra la acción de los hombres

Res humani iuris

Son las *res* que se encontraban por fuera del derecho divino, eran de derecho humano o profano.

A su vez se clasifican como cosas *extra commercium*:

Son aquellas que no pueden ser pasibles de actos jurídicos. Se subdividen en tres sub - clases: *res communes*, *res publicae* y *res universitates*.

Res communes

La propiedad de ellas no le pertenece a nadie y es de uso común a todos los hombres, pertenecen a éstos en virtud del derecho natural, ningún sujeto se los puede apropiar para sí, por ejemplo: el aire, el agua, el mar y sus riberas.

Res publicae

Son las que usan todos los hombres se diferencian de las cosas comunes, porque las *res publicae* son de propiedad del pueblo romano siendo su titular el Estado, con exclusión de cualquier otro pueblo, por ejemplo: las vías públicas, corrientes de aguas que nunca se secan –*flumen perenne*. En cambio las corrientes de aguas que se secan al cabo de un tiempo son de uso privado, por parte de los particulares.

Su uso se encuentra protegido por la *actio iniuriarum* y por interdictos. Tienen protección interdictal: Los ríos o cursos de agua de carácter permanente, sean o no navegables, las cosas que pertenecen al pueblo, destinadas al uso público, como las vías o calles, los puentes, los foros, las plazas, los teatros y los baños o termas; son como *vimos*, *extra commercium*. El carácter público se lo da el edicto denominado *publicatio*, están protegidas por los interdictos: *ne quid in loco publico facias*; *quo minus loco público*; *quo minus illi viam publicam*, cuando está la necesidad por parte de alguien de hacer arreglos, obras, en la vía pública y un tercero no se los permite, se evita que alguien entorpezca el buen uso público de las cosas que se refieren, o que se las destine a un uso privado o que se las dañe o que se frustre su reparación y cuidado por los particulares.

Por último, el mar y sus costas son también de uso público, no son declaradas por acto administrativo su cualidad proviene del derecho de gentes.

Res universitatis

El término universitatis se refiere a las personas morales o jurídicas, si bien pueden ser titulares de cosas, no queda afectado su uso a éstas, sino que se aplican al uso común por su destino, por ejemplo: los teatros, las plazas, los baños públicos, los foros. No le pertenecen al Estado, para diferenciarlas de la categoría anterior.

Saliendo de la clasificación de las cosas extra commercium y continuando con la de Res Humani Iuris, continuamos con:

Res in comercio

Son todas las cosas que están pasibles de ser objeto de actos jurídicos, son de posible apropiación.

Res privata o singulorum

Son las que forman parte del patrimonio de los particulares y pueden ser objeto de diversas clases de actos negociales, ir ejemplo comprar, vender, negociar, etc.

Corporales e incorporales

Son corporales: quae tangit possunt o sea, las cosas que pueden tocarse o se perciben por los sentidos. En contraposición se le da el mismo nombre de cosas a las que no pueden percibirse por los sentidos, son incorporales, quae tangi non possunt, allí radica el sentido de la segunda denominación.

Las cosas corporales se sub-clasifican a su vez en

Muebles e inmuebles

Ésta clase de cosas nace como consecuencia de que las cosas pudieran o no moverse, trasladarse por sí mismas.

Los inmuebles eran *res soli*, cosas que no se pueden mover por estar adheridos al suelo, también quedaban comprendidas las cosas que se podían mover pero por medio de una fuerza externa.

Su importancia jurídica estaba en las diferentes formas de hacer la traditio siendo más fácil en el caso de las cosas muebles, porque simplemente se daba el objeto; en cambio en las inmuebles se podía hacer por la entrega de las llaves del almacén o la traditio vacua a la distancia. En la antigua acción de la ley por el Sacramento se llevaba ante el magistrado una parte del inmueble que lo representaba en el juicio como si estuviera presente la cosa en su totalidad, ante la imposibilidad de llevarla. La prescripción adquisitiva variaba según las cosas fueran de una u otra clase y en ambos casos se requería de una posesión previa sin vicios.

Cosas fungibles

Son aquellas en que una hace las veces de la otra, al ser de semejantes características no importa a los fines jurídicos si se utiliza una determinada o su similar, al derecho le interesa que se use ella a los fines jurídicos requeridos, por ejemplo la cosa fungible por excelencia es el dinero, no importa si se entregan tantas monedas o tales otras, lo que interesa es pagar y cancelar la deuda.

Su importancia jurídica estaba en la celebración del contrato de mutuo cuya esencia era el dinero en se devuelve el objeto equivalente.

Por acuerdo de voluntades, los sujetos pueden acordar que un objeto fungible no lo sea, por ejemplo cuando se presta una moneda para ser exhibida en algún lugar por un tiempo determinado se deberá restituir el mismo objeto, por lo tanto no está autorizado el consumo o el intercambio de ese objeto por otro similar, es lo que se denomina de *ad pompam vel ostentationem*.

Cosas no fungibles

Son aquellas que, a diferencia de las anteriores tienen caracteres propios e individuales que las diferencian de otras, son en principio únicas, por ese motivo no pueden ser reemplazadas por otras de igual calidad, cantidad, peso, medida, etc. en caso de que se perdieran. Por ejemplo un esclavo con determinadas cualidades que otros esclavos no tienen.

Cosas simples

Son aquellas que forman un todo, una unidad, por ejemplo una piedra, un animal.

Compuestas

Son las que formaban un todo ideal, se constituían la suma o agrupamiento de cosas simples, por ejemplo una casa, una embarcación.

Cosas consumibles

Son consumibles aquellas cosas que se destruyen con el primer uso, ello ocurre, porque las características propias de la cosa hacen que sea así. Por ejemplo las frutas.

Desde el punto de vista jurídico una cosa consumible es aquella que está sometida a enajenación, como el dinero o las mercaderías que una persona tiene en su comercio para vender.

Cosas no consumibles

Son aquellas que con su uso no se destruyen, sin embargo pueden sufrir con el paso del tiempo el deterioro normal de las cosas. Por ejemplo: el calzado.

Su importancia jurídica la encontramos en el instituto del usufructo, en que un sujeto puede usar y gozar de una cosa dejando a salvo su substantia, por lo tanto tenía que recaer sobre cosas no consumibles. Más tarde cuando parece la figura del cuasi usufructo se

permitía que recayera sobre cosas consumibles con la restitución a posteriori de una cosa similar, dándole una naturaleza jurídica particular a éste instituto.

Su importancia jurídica

Que un objeto sea o no consumible depende de la naturaleza intrínseca de los objetos y no de la decisión humana.

Cosas principales

Son aquellas cuya existencia y naturaleza dependen de sí mismas, le dan el carácter que se puede asignar a la cosa.

Cosas accesorias

Son aquellas que dependen de la principal, tienen una función respecto de ésta, y así puede cumplir su destino y función, por ejemplo el marco respecto del cuadro, la estatua adherida al suelo.

Res Mancipi y res nec Mancipi

Son la primera o la segunda según puedan o no ser adquiridas por la Mancipatio.

La Mancipatio designaba un poder jurídico sobre las cosas y personas.

Solo podían transferidas mediante los actos solemnes de la Mancipatio o la in iure cessio.

Son res Mancipi los fundos itálicos, ubicados en el ager Romanus, las primitivas servidumbres rústicas sobre ellos, los esclavos y los animales de carga de gran porte (bueyes, mulas y asnos), los caminos, los acueductos. También lo son los filii que se encuentran bajo la patria potestas y la mujer in manus. Ambos podían venderse, ello implicaba la suspensión de la patria potestas para el pater familias. El filius era entregado in causa Mancipi cuando cometía un delito o

debía cumplir con una prestación, entonces era entregado a un tercero hasta que se cumplieran esos fines, después volvía bajo la potestas del pater, sin embargo después de la tercera entrega en causa mancipi salía de la misma.

Si la mujer quería desprenderse de ésta clase de cosas necesitaba de la auctoritas del tutor.

Res nec mancipi

El resto de los animales como los corderos, las cabras, y todas las demás cosas, hasta el dinero y las joyas, además de los fundos estendiarios y tributarios son res nec mancipi.

Se podían transferir por medio de la traditio, su forma de transmisión era más simple, sin formalidades a diferencia de las res mancipi, el mancipium implicaba una serie de solemnidades que rodeaban al acto y en cierta medida lo complejizaban.

Podían ser enajenadas por la mujer sin el consentimiento del tutor.

Estas categorías cayeron en desuso en época del bajo imperio y desaparecieron en tiempos de Justiniano.

Res nullius

Son las que no le pertenecen a nadie, se encuentran los animales salvajes, las aves silvestres y los peces, a la isla nacida en el mar y a las cosas encontradas en la costa del mar como las perlas o piedras. Son de uso común para todos los hombres.

Res derelictae

Son las que han sido abandonadas por su dueño, sin ánimo de recuperarlas.

Res sine domino

Son las cosas que integran la herencia yacente, el esclavo manumitido bajo condición suspensiva mientras pende la condición, para los proculeyanos por ejemplo el ciervo dado en usufructo, la cosa legada per vindicationem antes de la aceptación de la herencia, el tesoro, las cosas del que cayó en poder de los enemigos.

Según sus particularidades

Cosas específicas

Se refiere al modo en que las cosas son señaladas o indicadas. Es cuando la cosa es señalada en su individualidad o por sus características propias, de modo que no haya lugar a dudas de que es a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo el fundo Corneliano.

Cosas genéricas

Son las cosas que son señaladas o indicadas como aquellas que tienen características comunes a otras y también por su cantidad.

Cosas Divisibles

Son aquellas que por sus características pueden fraccionarse sin que por ello se pierdan sus cualidades esenciales, y cada parte, a la vez sirva para adquirir individualidad propia.

Cosas Indivisibles

Son aquellas que, por sus características internas hacen que en caso de fraccionarse, se destruya la cosa, por ejemplo un esclavo.

Se puede hacer referencia a las siguientes:

Cosa Material

Es indivisible, cuando la partición puede provocar perjuicios a la cosa, lo que puede implicar también su extinción. Por ejemplo un animal.

Cosa Ideal

Es cuando las cosas pueden dividirse por imposición de la ley o porque la ley lo permite, ya que pertenece a dos o más personas a la vez y es menester la partición para asignarle lo que le corresponde a cada una. No admiten división las servidumbres (res incorporalis).

Cosas fructíferas

Son aquellas que devengan según su naturaleza y destino, periódicamente un producto o fruto, que se convierte al sepáraselo natural o artificialmente, en cosa autónoma, independientemente de la que la generó.

Cosas no fructíferas

Son aquellas que no reúnen los caracteres señalados anteriormente.

Derechos reales. Concepto y caracteres

Los derechos reales son aquellos que crean entre la persona (titular) y la cosa una relación inmediata y directa, por la cual el mencionado puede obtener una ventaja o beneficio sin la intervención de un tercero.

En cambio en los derechos personales no es directa entre la persona y la cosa sino es directa entre el deudor y el acreedor, siendo por lo tanto relaciones entre personas.

Se denominan a los derechos reales derechos absolutos:

- a) Porque si bien el beneficio es para una sola persona deben ser respetados por todos;
- b) conceden un derecho de preferencia, porque aquél que adquiere un derecho real sobre una cosa, la constitución posterior por otras

personas no afecta su derecho, sino que al momento de hacerlo valer se tendrá en cuenta al primero que lo haya constituido en el tiempo.

c) Solo puede tener como objeto una cosa de existencia actual.

d) Confiere un derecho de persecución, significa que el titular seguirá teniendo el derecho aunque la cosa se encuentre en manos de un tercero.

A los derechos personales se los denomina relativos:

a) Porque solo el deudor está obligado respecto del acreedor a hacerle la entrega de la prestación.

b) No se aplica el derecho de preferencia, ya que todos se encuentran en igualdad de condiciones, ya que un deudor puede obligarse con distintos acreedores, éstos se encuentran en un pie de igualdad, en principio deben ser pagados por igual.

c) Puede tener como objeto una cosa futura (por ejemplo, una cosecha), basta que el objeto exista cuando el deudor deba ejecutar su obligación.

d) La acción se otorga solamente contra el deudor, porque es el que tiene que cumplir con la prestación.

Los derechos reales o absolutos. Concepto

Son los vínculos que el derecho regula y se dan entre las personas y las cosas. El sujeto que es titular de ellos puede tener una ventaja que proviene de la cosa en forma directa. Su titular es el único que se beneficia con exclusión de cualquier tercero.

Otorgan un derecho de preferencia para aquél que adquiera un derecho real, aunque aparezcan otros que también constituyan un derecho real sobre la misma cosa aunque haya sido con posterioridad.

Tiene como objeto una cosa de existencia real y actual.

El *ius persecuendi* o derecho de persecución lo tiene el titular del derecho real en contra de quién tenga la cosa en su poder, por ejemplo la acción reivindicatoria, en el derecho de propiedad, para reclamar la restitución de la cosa propia en manos de quién se encuentre.

Derechos personales o relativos. Concepto

La vinculación no es tan directa entre la cosa y la persona como en el caso anterior. La cosa pasa a un segundo plano, los vínculos se establecen entre los sujetos, por ejemplo el deudor y el acreedor: si uno debe entregarle dinero al otro el mismo tiene desde ésta óptica jurídica una importancia secundaria.

El deudor está obligado personalmente al cumplimiento de su prestación.

No hay derecho de preferencia para los primeros que constituyeron los derechos personales, todos los créditos que pudieran existir se mantienen en el rango jurídico en el mismo grado, por lo que, los créditos serán satisfechos todos ellos pero en bajas proporciones (no no) para que no queden acreedores sin cobrar.

En los derechos personales, la acción que se otorga es solo en contra del deudor, es quién debe cumplir con lo adeudado.

Tiene como objeto una cosa de existencia futura, por ejemplo la cría que va a tener un animal. Porque lo que lo valida jurídicamente es su existencia al momento de satisfacer a la contraparte en la cancelación crediticia.

III. La Posesión

Importancia histórica

En la convivencia social y jurídica, se dieron una serie de situaciones conflictivas por las que aparecen las nociones de la posesión y de los derechos reales después con todas las figuras que fueron apareciendo a las que se les dio un formato jurídico.

Entre las distintas situaciones de sujetos que se disputaban un objeto podemos mencionar:

En la *legis actio per sacramentum*, el pretor otorgaba interinamente la posesión de la cosa litigiosa a una de ellas hasta que se dictara sentencia y se resolviera quién tuviera derecho sobre ella.

En otro caso, cuando se otorgaba la posesión provisoria de la *hereditas* respecto del heredero que la había reclamado por la *bonorum possessio*.

La posesión también se relacionó con otros institutos, como el contrato de locación de cosa, el depósito, el *usus* como forma de adquirir la *manus* sobre la mujer, por mencionar algunos.

Concepto de posesión

Es una situación de hecho que se plantea entre una persona y la cosa en relación a su disponibilidad material y su protección jurídica a través de los interdictos.

Poseedor en principio, puede ser cualquiera: el acreedor prendario, por ejemplo; siempre que sea acorde al derecho y a la convivencia social pacífica. En los primeros tiempos las desposesiones eran violentas, por eso surgió la necesidad de que el derecho intervenga.

Elementos

El corpus o elemento objetivo

Es el contacto físico que se tiene con la cosa. La cosa se encontraba en poder de una persona, de manera que le fuese posible disponer en todo o en parte de ella.

El *animus*

El mero contacto físico es insuficiente, será necesario además que haya una intención del sujeto de querer tener el contacto físico con la cosa, tenerla para sí como si fuera el dueño, sabiendo que la propiedad le pertenece a otro. Luego se hizo extensivo a la vinculación entre éste y la cosa excluyendo a los demás.

La justa causa y la buena fe

El derecho de propiedad y la posesión pueden o no coincidir, en el caso que no coincidan se le requiere al poseedor que tenga para sí la

cosa pero sabiendo que le pertenece a un tercero como se expresara con antelación, si esto ocurre está obrando de buena fe.

Además de la buena fe se requiere una justa causa de posesión, dicho de otra manera no me puedo apropiar de algo que no me pertenece por tener el corpus y el *animus*, sino que tiene que existir un título de carácter legal que justifique el motivo por el cual tengo la cosa conmigo, por ejemplo haberla locado.

El derecho pone límites a las turbaciones que pueda sufrir el poseedor, si el justo título y la buena fe no es suficiente, el titular tendrá la protección de los interdictos posesorios.

Otros ejemplos además del acreedor pignoraticio, que posee la cosa dada en prenda; también el poseedor precarista, que es aquel a quien se entrega una cosa cuya posesión puede ser revocable en cualquier momento, el secuestratario respecto de las cosas en litigio, o el enfiteuta.

Posesión y propiedad

Si se colocara a los derechos reales en una escala jurídica jerárquica, la que estaría en la punta de la pirámide sería la propiedad. Es el derecho de máxima jerarquía jurídica al que podía aspirar un sujeto. La protección jurídica a través de la *rei vindicatio* y el goce de un corpus y un *animus* que tiene el propietario o *dominus* y con respecto a la cosa no lo tiene nadie más que él.

En la posesión encontramos un *animus* diferente al del propietario: es el de aquél que tiene la cosa para sí pero reconoce el derecho de propiedad en un tercero, por lo que no goza de la máxima jerarquía jurídica ya que se comporta como propietario sin serlo porque reconoce el derecho de propiedad en otro.

Los derechos de propiedad y posesión pueden coincidir, o no, en éste último caso se puede ejemplificar en la locación de cosa mueble, siendo el locatario el poseedor y el locador el propietario de la cosa locada.

La protección posesoria es a través de las normas emitidas por el pretor denominadas *interdictos*.

El derecho de propiedad es transmisible por vía hereditaria, el derecho posesorio no.

Para adquirir por *usucapio*, primero hay que poseer y de buena fe por parte del futuro adquirente, para después convertirse en propietario de ella por el transcurso de; un año para las cosas muebles y dos años para las inmuebles, por regla general. Sin dejar de lado otro de los requisitos fundamentales: la posesión tiene que ser *iusta*, o sea, no ser contraria al derecho; por eso el poseedor debe poseer sin violencia, sin clandestinidad y sin precariedad.

La posesión contraria a derecho es injusta y de mala fe, por lo que se trata de una elaboración primero práctica y después jurídica. La mala fe no es de los primeros tiempos en que era válido poseer y hasta apropiarse de las cosas del enemigo. Luego para acercarse a un orden social basado en la *aequitas* apareció el límite de la buena fe, sino se habilitaba a cualquier sujeto que tomara lo de otro y lo poseyera o se adueñara, como ya se dijo, sin una justa causa de dominio.

La posesión de mala fe provoca otras consecuencias: interrumpe la prescripción adquisitiva *-usucapio-*; también se pierde ante el reclamo *interdictal* frente al que no tiene una posesión viciada.

Teorías de Savigny, Ihering y Saleilles

Ya vistos los conceptos de *corpus* y *animus* romanos. Con el paso del tiempo asociaban el corpus a lo meramente material. Consideraron la existencia de una relación inmediata y directa entre la cosa y el sujeto.

Después se produce una modificación acerca de la idea del corpus en la que se necesitaba además del contacto físico con la cosa, la posibilidad de estar en contacto continuo, la presencia.

Según Savigny, el *animus* que caracteriza a los poseedores es un *animus domini*, es la intención de tener la cosa como si fuera el dueño.

No la tienen los detentadores. No era necesario tener constantemente la cosa sino que, sino la posibilidad de tenerla en cualquier momento.

Si bien las fuentes romanas no hacen referencia al *animus domini* de los poseedores como en el acreedor pignoraticio, el secuestrario y el precarista, no se puede determinar que tengan esa intención de tener el *animus domini*. Por eso no puede afirmarse que se dé este requisito tan importante establecido por éste romanista en los mencionados casos. Diferencia entre el poseedor y el detentador (tenencia), el primero tiene el *animus domini*, el segundo no.

Para Ihering, no es poseedor el que tiene solo el corpus, sino que es necesaria la “conciencia” de querer tener la cosa y ejercer actos de disposición de la cosa. Esa conciencia es el *animus*.

De ésta conciencia carecen los dementes o el que duerme y sostiene la cosa en su mano, sin ninguna intención de mayor trascendencia que la cosa siga en su mano mientras duerme y quizá nunca lo sepa porque nunca pudo ser consciente de ello. Dicho de otra manera, no tienen *animus*. Por otro lado el autor destaca que aquellos que tienen *animus* no tienen protección interdictal, por ejemplo: el depositario, el locatario o el comodatario, considera que son casos excepcionales. La cosa está a disposición de ellos pero su intención no es utilizarla o servirse de ella como sus dueños, ya que reconocen el derecho de propiedad en un tercero. Se trataría de una detentación.

En cuanto al corpus es una relación flexible que se adapta distintas situaciones de hecho. El sujeto desde el punto de vista externo se comporta de manera similar que lo hace el propietario, ello depende del uso que se le dé a la cosa, las relaciones sociales o costumbres, etc. La posesión es el reflejo o la imagen del dominio, el poseedor es el propietario de hecho.

En cuanto a la prueba, para éste autor el poseedor tiene que acreditar que se ha comportado con la cosa como lo hubiese hecho el propietario, haya existido o no posibilidad física o contacto directo con el objeto.

Saleilles

Su postura fue ecléctica. También sostiene la existencia de los dos elementos necesarios para tener la posesión: el *corpus* y el *animus*. Define al *corpus* como la relación de apropiación económica con carácter permanente, hay un vínculo de explotación económica de la cosa puesta al servicio del individuo, entre esos hechos y la cosa que tiene como objeto.

Adquisición de la *possessio*

Eran necesarios los dos elementos de la posesión: la disposición material de la cosa (*corporepossidere*), e intención de tenerla como dueño (*animuspossidendi*), tienen que estar indefectiblemente los dos.

Adquisición personal o por intermedio de un representante

En ambos casos se requería tener capacidad jurídica. Al principio era un acto personalísimo, no se podía delegar en terceros. El representante que apareció con el paso del tiempo fue el *procurator omnium bonorum*, dicho *procurator* era un liberto que administraba el patrimonio de su antiguo *dominus*.

- a) Personalmente: Se requería que el adquirente tuviera el *animus*, primero y el *corpus* después.
- b) Por terceros: es el caso de la representación a través del mandatario: previo celebrar el contrato de mandato, actuaba a favor de su representado ya que era el que le había dado la encomendación de la realización de dicho acto jurídico, el mismo tiene efectos a partir de la adquisición de la posesión. Otra forma de adquirirla era a través del gestor de negocios, éste no realizaba el acto de adquisición de la propiedad con el encargo de su representado, sino que éste tomaba conocimiento después, y cuando ratificaba el acto realizado por el gestor el mismo tenía plenos efectos jurídicos.

Para adquirir el corpus celebra el acto que haría personalmente el representado. En cuanto al *animus* se requería: que el representante deje en claro que la adquisición se hace para el representado sino quedaba para sí.

Pérdida de la posesión

- a) Cuando se perdía alguno de sus elementos: el corpus, el *animus* o ambos.
- b) Cuando el objeto perecía.
- c) Cuando el objeto se transformaba en extra *commercium*.
- d) Por la acción de un tercero, por ejemplo que le saque la posesión de la cosa a su titular.
- e) Por muerte del titular del derecho.
- f) Por abandono del objeto por parte de su titular.
- g) Por sufrir una *capitis deminutio* máxima.
- h) El requisito del *animus* excluye que la posesión sea adquirida por el loco, por el que duerme, por el infante, y hace necesaria la *auctoritas tutoris* para la adquisición del impúber; excluye también que la posesión pueda ser adquirida por quien recibe la cosa con la intención de tenerla alieno nomine.
- i) Si para la adquisición se requiere el concurso de ambos elementos, resulta de ello que para la pérdida de la posesión basta con que falte uno solo.

IV. La posesión y su protección jurídica

Los interdictos

Interdicto proviene del latín *intercedir* que significa impedir.

El edicto era la normativa creada por el Pretor, de carácter general y obligatorio. A esa creación, en su conjunto se la llamaba derecho pretorio. La norma podía: prohibir, restituir o exhibir. Respondiendo

a la casuística romana, la norma dictada por el pretor para resolver un caso particular se denominaba interdicto, éstas eran las dos clases de normas de éste magistrado.

Al principio ésta normativa sirvió para la protección de las cosas divinas, los interdictos eran de dos clases: uno de carácter prohibitivo: defendía el ataque que se realizaban a dichos lugares; y el otro de carácter restitutivo: se disponía restablecer las cosas a su estado anterior.

Cuando alguien hacía algún reclamo que debía resolver el pretor o el próconsul, si consideraba que el mismo podía prosperar, el interdicto consistía en una orden de carácter imperativo en que se mandaba a hacer algo o se lo prohibía, y el litigio quedaba solucionado si la contraparte cumplía con la orden del magistrado y con la petición del demandante.

Sin embargo a veces no ocurría de la manera descrita antes, ya sea porque el demandado se negaba a cumplir con lo ordenado por el magistrado o negaba lo invocado por la contraparte. Se abría entonces la etapa en la que intervenía el *iudex* o tribunal de los *recuperatores* para que determinen si se transgredió lo ordenado por el interdicto y que el litigio se resolviera de manera definitiva.

Con el paso del tiempo se protegieron las cosas públicas.

La normativa del pretor era para completar las ausencias de regulaciones por parte de la ley en materia policial y de policía, sumarias, rápidas, expeditivas para asegurar el orden público en el caso de la vulneración de los derechos de los particulares.

Clasificación de los interdictos

Podían ser prohibitivos, restitutorios y exhibitorios.

Los prohibitivos: Impedían la realización de algo, por ejemplo: no ejercer violencia sobre el derecho legítimo de un tercero; edificar en un lugar sagrado. En lo que respecta a la posesión tenemos el *Utrubi* y el *uti possidetis iuris*.

Los restitutorios: Ordenaban devolver algo, por ejemplo la restitución de la posesión del un fundo por el cual se lo había despojado por la violencia. En el derecho posesorio encontramos el *unde vi* y de precario.

Los exhibitorios: Por ellos el magistrado ordenaba la exhibición de una cosa; por ejemplo al individuo cuya libertad estaba en litigio (*libero homine exhibiendo*); también cuando se le pedía al *pater* exhibir a los hijos sometido a su *potestas*.

Se conoció otra clasificación de los interdictos, estos podían ser:

Simple

En ésta clase de interdictos había dos partes: el actor y el demandado; de manera obligatoria la condena debía recaer sobre el demandado. Comprendía los interdictos restitutorios y los exhibitorios; el demandante pedía la exhibición o restitución de alguna cosa.

En cuanto a los prohibitorios, podían ser simples o dobles. Por él el pretor establecía la prohibición de hacer alguna cosa en un lugar sagrado, en el cauce, en la orilla de un río. El demandante quería impedir que se hiciese algo y el demandado el que quería hacerlo (interdicto prohibitorio simple).

Interdictos posesorios

Explicados los interdictos y su origen se pasa ahora, a la materia interdictal posesoria. Eran órdenes emanadas de los magistrados con el fin de proteger la posesión, en los siguientes casos:

Por turbación de la posesión; el fin del interdicto era conservarla y mantenerla.

Cuando se producía la pérdida de la posesión, el interdicto servía para ordenar su restitución. Eran los *retinandae possessionis* y los *recuperandae possessionis*.

También había otra categoría de interdictos; los *Adipiscendae possessionis* que servían para adquirir la posesión por primera vez.

Retomando lo expresado al principio del título que, la protección interdictal al principio se hacía sobre las cosas sagradas con el paso del tiempo se extendió la protección a los intereses de índole privada y a las cuestiones relacionadas a la libertad de los sujetos.

Interdictos *retinendae possessionis*

Cuando el titular perdía el objeto a causa de hechos realizados por terceros, como podía ser el intento de desapoderamiento, había herramientas jurídicas para recuperarlo. Así parecieron los interdictos *retinendae possessionis* se aplicaban cuando el poseedor sufrió o tenga razón para temer molestias o turbaciones; y su tratamiento varía según se trate de cosas muebles o de cosas inmuebles o muebles. La característica de éstos interdictos era, que tenían un carácter preliminar al relamo de propiedad, se trataba de determinar cuál era la situación de las partes, retener la posesión hasta que se determine después el derecho de propiedad.

Para las cosas inmuebles se utilizaba el interdicto *uti possidetis*: *Uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis. quominus ita possi- -deatis, vim fieri veto.*

Para las segundas el interdicto *utrubi*: *Utrubi hic homo, quo de agitur, maiore parte huiusce anni fuit. quominus is eum ducat, vim fieri veto.*

Para los inmuebles se protege la posesión: actual (“uti... possidetis”), para los muebles prevalece, entre los dos contendientes, el que ha poseído por más tiempo durante el último año.

Se tenía que poseer sin vicios respecto del demandado, sin violencia, sin clandestinidad.

Los interdictos *recuperandae possessionis*

Son el *unde vi* y de él se deriva el *de vi armata*. Se requiere, como su nombre lo indica, el ejercicio de la vis o violencia. Éste era el despojo ilegítimo de la posesión de un inmueble por medio de la fuerza.

La fuerza ejercida podía ser a través de las armas o sin ellas, en el último caso es la simple violencia. Si la vis es armada no se le daba la *exceptio* para que opusiera el demandado, pero ésta sí era concedida si la vis era simple, clam o de precario.

De precario

Se daba a favor de quién había dado la cosa a título de precario. Era un acto por el cual se concedía gratuitamente el uso de una cosa o derecho bajo la condición de poder revocarla en cualquier momento.

De clandestina *possessionem*

Se daba a favor de aquél que había sido despojado de la cosa en forma oculta, lo que significa un despojo en un grado mayor de indefensión.

Los interdictos *Adipiscendae possessionis*

Quorum bonorum

Se otorgaba la posesión de los bienes hereditarios al *bonorum possessor*. Éste último era quién había reclamado su derecho a heredar ante el pretor. Se reclamaba de quién lo tuviera en su poder por intermedio de éste interdicto

Quod legatorum

El legatario tenía que recibir la cosa legada, si el heredero no había cumplido con ésta carga impuesta legalmente era obligado por medio de éste interdicto.

Interdictum Possessorium

Se otorgaba a favor del *Bonorum Emptor*, era aquél que había adquirido el mayor porcentaje del patrimonio del deudor insolvente, que fue sido ejecutado por el procedimiento concursal de la *bonorum venditio*. Se le otorgaba la posesión de dicho patrimonio.

Interdicto Salviano

Por medio de éste se le permitía al locador de un fundo retener para sí los instrumentos destinados al trabajo de labranza y cultivo de la tierra. Los tomaba en prenda como una forma de garantizarse el pago de la locación. Cumplida ésta cuestión se los restituía al locatario.

FRANJA
MORADA

Derecho real sobre cosa propia: La propiedad

I. Derecho de Propiedad

Siguiendo con el estudio de los derechos reales, hay que distinguir dos clases, los que recaen sobre cosa ajena y los que recaen sobre cosa propia. Lo que se verá a continuación es el derecho real sobre cosa propia, siendo uno de los más completos desde el punto de vista jurídico, con sus particularidades y su protección jurídica, es el denominado dominium o derecho de propiedad o la plena in re potestas.

Concepto de propiedad

Es el poderío o señorío mayor de derecho que ejerce el titular (propietario) sobre la cosa. Al principio se lo denominaba “derecho de dominium”, dicho de otra manera “lo que viene del señor”, ese es el origen de señorío jurídico.

Elementos

Corpore: Se requiere de la existencia de la cosa, de la materialidad.